陳奕先　11145241

刑法總則　作業一

第一題（107 年地方政府特考三等）

一、本題就甲撞死乙之行為，不成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．甲就乙之死亡結果並無知與欲，不成立故意殺人罪，故本題僅就過失犯之成立與否進行審查，本案甲若未駕車撞擊乙，乙即不會產生死亡之結果，因此兩者間應具備條件因果關係。

2．客觀注意義務之審查

（1）針對甲超速部分，係違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險。

（2）又針對甲無照駕駛部分，駕照之創設係以行政管制確保駕駛者之基本駕駛能力為目的，題示並未顯示甲係因欠缺駕駛技術而肇事，因此無照駕駛不足以構成本件過失依據，僅生行政罰之問題。

（3）就信賴原則探討，參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守相關交通法令並盡相當之注意義務，始得信賴他人亦能遵守交通規則。本題甲自身超速在先，自不得主張信賴原則以排除其注意義務。

3．義務違反關聯性之審查

本題爭點係探討若事後確認甲未超速，乙違規又超速左轉，該死亡結果仍然具備「高度可能性」會撞上乙時，此般假設具備注意義務仍會發生結果之情形，學說上有以下見解：

（1）風險升高理論：此學說認為若有違反注意義務行為，相比遵守時升高結果發生的機率，始具義務違反關聯性。然此說單純以機率之高低論斷，似有違罪疑唯輕原則，又恐有不當擴張過失犯處罰範圍之疑慮，因此本題不採納此學說。

（2）迴避可能性理論（本題採之）：此學說認為須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。若遵守注意義務時，結果仍確定發生，即屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）；若結果僅係有可能發生，學者認為因無法確定遵守義務即能避免結果，應本於罪疑唯輕原則，作有利於行為人之認定，否定義務違反關聯性。

（3）據此，本題中甲即使未超速，仍具備高度可能性撞上乙而使其死亡結果發生，無法判斷甲遵守速限即可避免，因此乙的死亡在客觀上不可避免，欠缺結果不法，客觀上不可歸責於甲。

（二）競合與結論

綜上所述，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，既客觀上不可歸責於甲，且過失犯不處罰未遂，甲不負刑事責任，既無犯罪成立，自無競合問題。而甲無照駕駛及超速，僅生行政罰鍰之問題。

第二題（108 年司法人員特考三等）

一、甲酒後駕車之行為，成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．客觀構成要件：本款規定吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上而駕駛動力交通工具者，即成立本罪，屬抽象危險犯，只要行為人完成法定犯行，即推定危險存在，無須於個案中審查是否具體發生危險。本題甲吐氣所含酒精濃度為每公升 0.35 毫克，已超過法定標準，並駕駛汽車上路，客觀構成要件該當。

2．主觀構成要件：本題爭點在於甲「自認」不致超標，是否欠缺故意。依刑法第 13 條第 2 項，行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論（間接故意）。甲明知自己飲酒且已有微酣感，友人亦當場勸阻，對於酒精濃度可能超標顯有預見；其「應不致超標」之想法，並無任何客觀根據支持（例如未經檢測），僅屬一廂情願之期待。依學說上之梗阻理論，行為人既可預見法益侵害之後果，

原則上即推論其具備意欲，本題並無足以推翻此一推論之具體間接證據，故甲具有本罪之間接故意。

(二) 違法性與罪責

本題無阻卻違法事由；又甲之酒精濃度為每公升 0.35 毫克，尚不致使其辨識或控制能力喪失或顯著減低（刑法第 19 條），具有罪責。故甲成立本罪。

二、乙之死亡結果不可歸責於甲，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，亦不成立第 185 條之 3 第 2 項、第 3 項之致死罪，以下說明之：

(一) 過失致死罪之審查

1. 行為態樣：甲疏未開啓車前大燈，形式上似屬「未為一定行為」之不作為。惟作為與不作為之區分，不能僅從物理角度觀察，而應從規範角度，依刑法對行為人之期待決定。刑法所禁止者，乃「駕駛未開燈之車輛上路」此一積極舉止，故甲之行為整體仍屬作為，無須另行審查不純正不作為犯之要件。
2. 條件關係：若甲未駕車行經該處，乙車越線後未必與甲車對撞，甲之駕車行為與乙之死亡間具條件關係。
3. 客觀注意義務之審查：甲酒後駕車且未開啓車前大燈，違反交通法規所具體化之注意義務，已創造法所不容許之風險。
4. 風險實現與義務違反關聯性之審查
   (1) 酒駕規範所欲防止之風險，係駕駛人因酒精影響致注意力、反應能力下降而肇事；未開大燈所創造之風險，則是他方無法辨識本車位置。
   (2) 然本題乙係因自己嚴重超速（逾速限 30 公里以上）、行經積水路面打滑失控，衝過雙黃線闖入甲之車道，「甲來不及反應之際兩車已然對撞」。縱使甲未飲酒且已開啓大燈，面對突然越線且已失控之乙車，仍無從閃避，屬於「合乎注意義務時，結果幾近確定依舊發生」之情形，即屬客觀不可避免，欠缺義務違反關聯性（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）。
   (3) 乙之死亡並非甲所創造之酒駕或未開燈風險之實現，而是乙自己以極度危險之駕駛方式所招致，屬被害人自主危險之範疇，應由乙自我負責。
   (4) 若依實務所採之相當因果關係說：依一般經驗，正常行駛於自己車道之車輛，遭對向失控車輛越線撞擊，並非酒駕行為通常會導致之結果，二者間亦不具相當性。
5. 小結：乙之死亡在客觀上不可歸責於甲，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪。

(二) 不能安全駕駛致死罪之審查

刑法第 185 條之 3 第 2 項為一般之致死規定；第 3 項則規定曾犯本條之罪經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，加重處罰。二者均屬加重結果犯（刑法第 17 條），依實務見解，基本犯罪與加重結果間須具相當因果關係，且行為人對加重結果客觀上有預見可能性，始能成立（最高法院 107 年度台上字第 1836 號判決參照）。本題甲雖前經緩起訴處分確定，形式上符合第 3 項之前提，惟如前所述，乙之死亡不可歸責於甲之酒駕行為，二者間亦不具相當因果關係，故甲不成立第 2 項或第 3 項之致死罪。至於甲自身之重傷，刑法不處罰自傷行為，無庸論罪。

三、競合與結論

綜上所述，甲僅有一個酒後駕車之行為，僅成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪一罪，無想像競合或數罪併罰之問題。

第三題（111 年公務人員高等考試三級考試）

一、本題甲撞死 A 之行為，成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

(一) 構成要件該當性

1. 甲就 A 之死亡結果並無知與欲，不成立故意殺人罪；而刑法第 276 條設有處罰過失之明文（刑法第 12 條第 2 項），故本題僅就過失犯之成立與否進行審查。本案甲若未駕車撞擊 A，A 即不會產生死亡之結果，因此兩者間具備條件因果關係。
2. 客觀注意義務之審查
   (1) 駕車上路本屬法所容許之風險，然交通法規就行車速度設有限制，甲於速限 50 km/h 之市區道路以 80 km/h 行駛，違反道路交通法規所具體化之注意義務，已然創造法所不容許之風險。

（2）就信賴原則探討：甲係綠燈通行，A 闖紅燈突然衝出，甲或可主張其信賴其他用路人均會遵守交通規則。惟參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守相關交通法令並盡相當之注意義務，始得信賴他人亦能遵守交通規則。本題甲自身超速 30 km/h，且其超速正是無法及時剎車之原因，自不得主張信賴原則以排除其注意義務。

（3）客觀預見可能性：以理性謹慎之一般駕駛人為標準，於市區大幅超速通過路口，可能因剎車不及而撞擊突然出現之用路人，客觀上可以預見。

3．義務違反關聯性之審查

（1）依迴避可能性理論，須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。本題事後證明，甲若未超速即可及時剎車而不撞上 A，屬於「合乎注意義務時，結果幾近確定不會發生」之情形，故 A 之死亡與甲之超速間具有義務違反關聯性。

（2）又速限規定之保護目的，正是防止車速過快以致剎車不及而撞擊他人，A 之死亡屬於該規範保護目的範圍內之風險實現，客觀上可歸責於甲。

（3）若依實務所採之相當因果關係說，超速行駛致剎車不及撞死他人，依一般經驗亦屬通常可能發生之結果，具相當因果關係。

(二) 違法性與罪責

本題無阻卻違法事由。甲為具完全責任能力之成年駕駛人，依其個人能力，可以預見超速可能肇事（主觀預見可能性），亦有能力遵守速限而避免結果（主觀迴避可能性），具有罪責。

(三) 競合與結論

綜上所述，甲僅有一個駕車撞擊之行為，侵害 A 一人之生命法益，成立刑法第 276 條過失致死罪一罪，並無想像競合（刑法第 55 條）或數罪併罰（刑法第 50 條）之問題。